

1500072-93.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... no local da abordagem é praticado o tráfico e negou que as drogas encontradas pelos policiais fossem suas. Os policiais militares narraram, em síntese, que estavam realizando patrulhamento nas proximidades de um bar, em virtude de denúncias de tráfico no local. O réu morava ao lado desse estabelecimento e estava saindo de casa, mas retornou ao avista-los ali. Um tempo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

[https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/](https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/EVw5Q60rE6dEpkbVq8sl0kEBzXZQh0rEURBrjcG0DveCIA?e=baUFor)

EVw5Q60rE6dEpkbVq8sl0kEBzXZQh0rEURBrjcG0DveCIA?e=baUFor

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500072-93.2022.8.26.0598 - Controle 2022/000164

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2033634/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 22842199 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 667/22/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2033634 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 667/22/406 -

DEL.POL.MINEIROS DO TIETE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUSCELINO RIBEIRO SANTOS

Em 08 de junho de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública, ora defendendo o acusado JUSCELINO RIBEIRO SANTOS; o acusado referido; e as testemunhas Crisley Guerhing Pinto e Jerri Adriano Alves Da Silva, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. JUSCELINO RIBEIRO SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j"3, do CP. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 30 de março de 2022 (p. 121-122) e o réu foi citado (p. 143). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a

desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias e laudo pericial, além da prova oral colhida na fase instrutória. A autoria é certa. Interrogado em juízo, o acusado rechaçou a acusação e negou ter dispensado o invólucro com as drogas. Disse que estava na posse de apenas um pino de cocaína, que havia adquirido para seu uso. Afirmou que no local da abordagem é praticado o tráfico e negou que as drogas encontradas pelos policiais fossem suas. Os policiais militares narraram, em síntese, que estavam realizando patrulhamento nas proximidades de um bar, em virtude de denúncias de tráfico no local. O réu morava ao lado desse estabelecimento e estava saindo de casa, mas retornou ao avista-los ali. Um tempo depois, o acusado saiu de bicicleta, mas demonstrou nervosismo com a presença da viatura e tentou fugir. Ele dispensou um invólucro com 15 pinos de cocaína e em sua posse foi encontrado outro pino da mesma droga. além de dinheiro. Ele alegou que era usuário. O policial Jerry acrescentou que, no dia seguinte aos fatos, ficou sabendo pelos seus colegas que havia denúncias de tráfico em relação ao acusado. Pois bem. A despeito das alegações defensivas, as provas são suficientes para comprovação do crime imputado ao réu. Os policiais apresentaram narrativas harmônicas a respeito dos fatos e afirmaram ter visto a dispensa, pelo acusado, do invólucro com as drogas apreendidas. Não há qualquer elemento capaz de afastar as sobreditas versões, até porque eles não conheciam o acusado e vice-versa. A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Willian Campos – julgado em 27 de maio de 2014 – votação unânime). "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016). No mais, o réu não apresentou justificativa para a posse das drogas (exceto de um invólucro), limitando-se a negar que elas fossem suas, nem comprovou a origem lícita do dinheiro apreendido. Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos seguros e isentos a infirmá-lo. E, ainda que ele também seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO – Tráfico – Absolvição – Inadmissibilidade – Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio – Prova colhida que direciona-se nesse sentido – Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância – Condenação mantida – Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 – Ribeirão Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Bittencourt Rodrigues – 22.08.00 – v.u.)." Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado. Procedente a ação penal, passo a dosar as penas. Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 106/107) e a descrita no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi

perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”). Assim, e considerando que reincidência é específica, majoro a reprimenda de 1/3 para 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da reincidência. Tendo em vista que o réu é reincidente e o quantum da pena corporal, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Não há se falar em desproporcionalidade ou “bis in idem” entre o reconhecimento da reincidência na segunda fase e o afastamento da causa de diminuição em comento, como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICACAO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Não há falar em bis in idem na utilização da reincidência do paciente na segunda fase de fixação da pena - para fins de agravamento da reprimenda -, e na terceira etapa da dosimetria - impossibilitando a aplicação da causa de redução de pena prevista no art.33, §4º, da Lei no 11.343/06 -, por haver expressa previsão legal para a ponderação dessa mesma circunstância nos dois momentos de fixação da pena, permitindo-se chegar à reprimenda mais adequada e suficiente para a prevenção do delito. 2. Habeas corpus denegado” (STJ - HC 188.699/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADODOTJ/CE), SEXTATURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 18/04/2011). E mais: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PRETENDIDO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/06, necessário o preenchimento de todas as condições elencadas na lei, quais sejam, além da primariedade, a ausência de antecedentes desabonadores, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 2. Inviável o reconhecimento da minorante em questão quando evidenciado que o paciente é comprovadamente reincidente, pouco importando se a reincidência é específica ou não, já que ausente qualquer distinção feita pelo legislador nesse sentido. 3. Não há que se falar em bis in idem quando considerada a reincidência na segunda etapa da dosimetria, como agravante genérica, e na terceira fase de aplicação da pena, como impeditivo para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois se trata apenas de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação da reprimenda

proporcionalmente suficiente a prevenção e a reprovação do delito, nas circunstâncias em que cometido. 4. Ordem denegada” (HC 178.933/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 09/03/2011). Arbitro o dia-multa em seu valor mínimo, ante a ausência de comprovação de que o réu possa arcar com valor superior. Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário

Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico: "O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória. (...) A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão". Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min). Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade. E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia. Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir. Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu JUSCELINO RIBEIRO SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime

inicial fechado, além do pagamento de 666 dias-multa, no mínimo legal, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. O réu respondeu ao processo preso e agora, com maior razão, não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente em virtude da necessidade de impedir a reiteração criminosa. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do dinheiro apreendido. Custas na forma da lei. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e archive-se. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. O Réu e a Defensora informaram que desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: JUSCELINO RIBEIRO SANTOS

RG: 19866486, RJI: 181322556-18

Data De Nascimento: 09/12/1993

Filiação: pai VALDECY FERNANDES DA SILVA, mãe JUSCELIA RIBEIRO DOS S. SILVA

Residência: RUA JOÃO DOMINGOS RICCI, 140, RUA JOÃO DOMINGOS RICCI, Mineiros do Tiete-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.